

1500607-42.2022.8.26.0559
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Natália Berti
Comarca: José Bonifácio
Foro: Foro de José Bonifácio
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 11/08/2022
... Data de Registro: 04/03/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de entorpecentes e Associação para o tráfico. Recurso Defensivo e Ministerial. I - Preliminar de cerceamento de Defesa afastada. Resposta a acusação antes do recebimento da denúncia. Rito correto. II - Mérito. Condenação mantida. Provas suficientes da autoria e materialidade delitiva. Confissão de dois réus. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de José Bonifácio
Foro de José Bonifácio
2ª Vara

Av. Monsenhor, 1000, Jardim das Palmeiras - CEP 15200-000, Fone: (17)3245-3348,
José Bonifacio-SP - E-mail: josebonif2@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500607-42.2022.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2087751/2022 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 23972246 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 571/22/321 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON LIMA DA SILVA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

1. Na data e no local acima expressos, às 14:30 horas onde presente estava o(a) Meritíssimo(a) Juiz(a), Senhor(a) Doutor(a) NATÁLIA BERTI foi aberta audiência designada nos autos supramencionados. conforme os termos do Comunicado 284/2020, emitido pelo E. Tribunal de Justiça, considerando a pandemia vivenciada (COVID-19).
2. Feito o pregão, verificou-se o seguinte: PRESENTE o(a) DD Promotor(a) de Justiça e Representante do Ministério Público, Senhor(a) Doutor(a) SERGIO CLEMENTINO; PRESENTES oa(s) ré(u)(s) ANDERSON LIMA DA SILVA e seu/sua Defensor(a) Dr(a). LUCAS LEAL DE FREITAS; PRESENTES também a(s) testemunha(s) ANDERSON JOSÉ MIRA, VINICIUS OTHAVIO PICCOLI ZANCHINI.
3. Iniciados os trabalhos, o(a)(s) réu/ré(s) declararam expressamente que conversaram com o(a) seu/sua Defensor(a) antes da realização desta audiência, garantindo-se ainda ao(s) réu/ré(s) e a seu/sua Defensor(a) todos os meios assecuratórios da ampla defesa e contraditório. Na oportunidade, a MM Juíza advertiu a todos acerca do Comunicado 284/2020, bem como prestou maiores informações sobre a realização de videoconferência e das circunstâncias acerca da pandemia vivenciada.

Após, o(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) ouviu a(s) Testemunha(s) de Acusação ANDERSON JOSÉ MIRA, VINICIUS OTHAVIO PICCOLI ZANCHINI. Por fim, a Meritíssima Juíza realizou o Interrogatório do(a)(s) Ré(u)(s) ANDERSON LIMA DA SILVA. 4. Então, a Meritíssima Juíza DECLAROU FINDA A INSTRUÇÃO e ALEGAÇÕES FINAIS MP - concedeu a palavra à Acusação e à Defesa, nesta ordem, para a apresentação dos memoriais e alegações finais orais. O(A) DD Promotor(a) de Justiça manifestou-se oralmente e o conteúdo de sua manifestação foi gravado por meio audiovisual (CD - DVD anexo). De forma sucinta, a Representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação. ALEGAÇÕES FINAIS DEFESA - Por seu turno, a Defesa também ofereceu alegações finais orais em audiência, cujo teor foi gravado para posterior reprodução (CD DVD anexo). Em síntese, a defesa requereu a improcedência da ação.

5. Terminados os debates, a Meritíssima Juíza proferiu a seguinte SENTENÇA: Vistos.

ANDERSON LIMA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/2006, porque, no dia 30 de março de 2022, por volta das 12h32, na Rua Piratininga, numeral 332, bairro Jardim das Amoreiras, nesta Cidade e Comarca de José Bonifácio, ANDERSON LIMA DA SILVA, qualificado a fls. 19, trazia consigo, para fins de tráfico, 2,52 gramas (duas gramas, quinhentos e vinte miligramas) de cocaína, divididos em 22 porções, e 8,18 gramas (oito gramas, cento e oitenta miligramas) de tetrahidrocannabinol THC, divididos em 06 porções, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Auto de Exibição e Apreensão da droga de fls. 05/06, Laudo de Exame Preliminar de Constatação de substância entorpecente de fls. 15/18 e Laudo Pericial Definitivo de fls. 82/84).

Conforme apurado, no dia e local dos fatos, em patrulhamento direcionado durante a entrada e saída de alunos, após receberem informações que estava ocorrendo tráfico de drogas nas imediações da Escola Estadual Pedro Brandão dos Reis, quando passavam pela Avenida Bandeirantes, na altura do número 1274, na lateral da referida escola, avistaram um indivíduo que ao perceber a presença da viatura mudou de direção de forma repentina, o que motivou a abordagem.

De tal forma, o indivíduo foi identificado como sendo Anderson Lima da Silva, e durante a revista pessoal, localizaram num bolso do seu shorts, acondicionado numa sacola branca, oito porções de maconha, vinte e duas porções de crack e a quantia de cinquenta e nove reais e cinquenta centavos.

Inquirido informalmente, o denunciado confessou a propriedade do entorpecente, e declarou ainda que realizava o tráfico de drogas na região do bosque da cidade. Perante a D. Autoridade Policial, o denunciado reservou-se ao direito de permanecer em silêncio.

A denúncia foi recebida em 07 de julho de 2022 (fls. 139/146).

O réu foi citado (fl. 169), e apresentou resposta a acusação (fls. 119/124).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, onde foram ouvidas as testemunhas e o réu foi interrogado.

O Ministério Público pediu pela condenação, nos termos da denúncia.

A defesa pediu a absolvição.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, a Defesa alega a nulidade das provas produzidas, pois a abordagem teria ocorrido de forma ilegal. Todavia, a preliminar não merece ser acolhida.

Não houve ilicitude da revista pessoal, uma vez que a abordagem se deu em obediência ao disposto no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, diante da presença de fundadas razões. Segundo a prova dos autos, os policiais militares se encontravam em patrulhamento pelo local dos fatos (imediações da escola Pedro

Brandão dos Reis), sobre o qual já recaíam denúncias de que estava ocorrendo a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme ofício encaminhado pela própria escola. Nesse momento, avistaram o réu que caminhava na lateral da escola. Segundo depoimento unânime dos policiais, ao avistar a viatura, o réu, repentinamente, mudou de direção, o que causou suspeita. Portanto, os policiais reportaram, ainda que do modo simples e direto que lhes é típico, que a atitude que perceberam do acusado foi suspeita, indicativa de que ele tivesse algo ilícito consigo. Não à toa que com eles realmente localizaram drogas. Vê-se, pois, que não houve qualquer violação ao dispositivo legal mencionado pela Defesa, sobretudo porque, repita-se, diante da atitude demonstrada pelo acusado, havia fundadas suspeitas para a realização da abordagem e busca pessoal. Em casos semelhantes, este foi o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de entorpecentes. Sentença condenatória. Preliminarmente sustenta nulidade em razão da revista pessoal realizada pela polícia militar. Inocorrência. Fundada suspeita para a realização da abordagem e busca pessoal. Nulidade afastada. No mérito, postula a absolvição por insuficiência de provas. Cadeia de custódia que seguiu os ditames previstos nos art. 158-B do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para o disposto no art. 28 da Lei 11.343/06. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos prestados pelos agentes públicos de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório. Dosimetria. Impossibilidade de afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, IV, do CP. Aplicação de diminuição prevista no §4º do art. 33 bem dosada diante das circunstâncias do caso concreto. Cabível a substituição por restritiva de direitos. Apelo parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1501949-07.2020.8.26.0544; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/08/2022; Data de Registro: 08/08/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Sentença condenatória. Abordagem e busca pessoal que estão justificadas, pois de acordo com a lei: fundada suspeita (art. 244 do CPP). Policiais que apontaram de forma segura que, ao visualizar a aproximação da guarnição, o acusado, que se encontrava sentado em uma guia num local conhecido como ponto de tráfico, adotou atitude evasiva, denotadora de fundada suspeita de que tivesse algo ilegal consigo. Desnecessidade, inclusive diante do encontro de drogas com ele e de ser desmentido quanto a estar em outro local, que os policiais expusessem de forma mais elaborada a suspeita que os levava à revista pessoal, que, bom que se diga, independe de mandado judicial e pode ser realizada a qualquer momento, mesmo que não se trate de situação de flagrante (não há que se confundir busca pessoal com busca domiciliar). Expertise policial que merece ser prestigiada, assim como são os depoimentos dos agentes da lei. Prova segura da autoria e materialidade. Condenação bem aplicada, merecendo, a r. sentença, ser ratificada na forma do art. 252 do Regimento Interno inclusive no que tange à dosimetria, fixada com critério. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500559-92.2021.8.26.0535; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Isabel - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/08/2022; Data de Registro: 09/08/2022)

Rejeito a preliminar suscitada. No mais, o processo encontra-se formalmente em ordem, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Não havendo nulidades ou vícios a serem sanados. O réu foi representado por Defensor e foram observados os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Não há questões preliminares a serem analisadas. Assim, passo à análise do mérito.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade delitativa está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 01/03), auto de prisão em flagrante (fl. 04), auto de exibição e apreensão (fls. 05/06), imagens (fls. 09/12), termo de depoimento (fls. 13/14), laudo pericial (fls. 15/18;

29/30; 78/84), interrogatório (fls. 19/20), nota de culpa (fl. 21), relatório final (fls. 86/87), bem como pela prova oral produzida.

A autoria é certa.

Anderson Lima da Silva (testemunha comum) disse que receberam ofício da escola, dizendo que suspeitavam de tráfico nas imediações da área interna e externa. Começaram a fazer o patrulhamento na escola Pedro Brandão e no entorno. No dia, avistaram o réu caminhando na lateral da escola. Ao perceber a presença da viatura, ele agiu de forma estranha, mudando espontaneamente de direção. Durante a busca pessoal, na bermuda, encontraram uma quantidade de entorpecentes. O réu confirmou que o entorpecente era dele e que ele fazia tráfico nas imediações do bosque. Naquele horário, havia movimentação de estudantes na parte da frente e na lateral. Ele não era conhecido. É lotado no batalhão em José Bonifácio, que fica em frente à escola. Já tinham notado, por algumas vezes, cheio de maconha. Está há tempo na corporação e o cheiro é característico. Já sentiu o cheiro em frente ao portão e isso reforçou o ofício. Foi a primeira vez que o avistou na escola. O réu tinha duas quantidades de entorpecentes e uma quantia R\$ 59,00. Não se recorda como eram as espécies. Ele confirmou que o dinheiro era da venda de entorpecentes. Ele não disse ter feito a venda para alunos da escola.

Vinicius Othavio Piccoli Zanchini (testemunha comum) disse que já tinham informações sobre tráfico na frente da escola Pedro Brandão, que fica em frente ao quartel. Em patrulhamento, na lateral da escola, avistaram o réu. Ele, repentinamente, mudou a direção e voltou para trás. Na cintura, no bolso, localizaram porções de crack e maconha. Ele disse que realmente traficava, mas não na escola, e sim em um bosque próximo. No horário, tinha movimento de alunos. Focaram no patrulhamento durante horário de entrada e saída e, naquele momento, era horário de saída. O bosque fica cerca de 1km/800m da escola. Foi encontrado dinheiro com ele, cerca de, aproximadamente, 59 reais. Não se recorda se ele mencionou que o dinheiro era da venda. Ele estava indo em uma direção e, quando viu a viatura, ele voltou para trás. Ficou claro que ele mudou em razão de ter visto a polícia.

Anderson Lima da Silva (réu) disse que tem 28 anos. Trabalhava como servente de pedreiro. Tinha renda média de 100 reais por dia. É solteiro. Não tem filhos. Já respondeu a outros processos. Disse que os fatos não são verdadeiros. No dia, estava trabalhando perto do bosque, na construção de uma casa. Pediu adiantamento do patrão. Ele adiantou 380 reais. Passando pelo bosque, avistou o traficante. Comprou a droga com o traficante. Entrou no banheiro do bosque e usou uma porção. Estava indo embora para casa, na Campo Sales. Viu a viatura descendo, apenas virou a esquina. Estava muito louco de drogas. A viatura deu a volta, parou na esquina e subiu. Continuou parado onde estava. Os policiais fizeram a abordagem e encontraram a droga. Falou que era usuário aos policiais e que tinha comprado no bosque. Disse que não tinha mais drogas na casa e que não vendia drogas. Os policiais procuraram o seu nome e o policial Anderson pediu para algemá-lo, porque era foragido da justiça. Disse apenas que estava assinando. Indicou a sua casa, eles o levaram em casa. A genitora autorizou o ingresso na casa e não acharam nada. Eles pegaram o seu papel do R.A. É usuário de crack e maconha. Como recebia 100 reais por dia e fumava 12 pedras todo dia. Pegou todo o dinheiro em drogas. Gastou parte do dinheiro e sobrou 60 reais. Não tem contato com ele. Não sabe o nome da rua da obra, mas era na esquina do bosque. Não conhecia os policiais. O policial disse que tinham ocorrências de que estavam vendendo drogas na região e, porque pegaram essa quantia, "seria ele". Não contou nada na delegacia, ficou em silêncio, porque o advogado não se encontrava. Só quer reforçar que é usuário. Finda a instrução processual, as provas produzidas nos autos são suficientes para fundamentar um decreto condenatório.

Na fase extrajudicial, o réu permaneceu em silêncio (fl. 19).

Em juízo, o acusado, declarou que a droga encontrada não se destinava à venda, mas sim ao seu consumo pessoal. No entanto, sua narrativa está isolada nos autos e não encontra respaldo em qualquer prova produzida sob o crivo do contraditório.

A análise do crime de tráfico (artigo 33, caput, Lei 11.343/06) exige a avaliação de todas as circunstâncias do caso concreto. No caso, as circunstâncias da

apreensão da droga, bem como o teor da prova oral produzida, demonstram que o acusado tinha a droga em depósito com a finalidade de comercialização. Isto porque, ouvidos em juízo, de forma coesa e unânime, os policiais informaram que intensificaram o patrulhamento nas imediações da escola, após receber um ofício indicando a ocorrência de tráfico no local. No dia dos fatos, estavam em patrulhamento e visualizaram o réu, que mudou de direção, estranhamente, após ver a viatura. Abordado, com o réu, encontraram porções de entorpecentes, além de dinheiro. Para os policiais, o réu declarou que realizava a venda em um bosque próximo.

Nesse ponto, é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório (RT 530/372).

A crítica costumeiramente expendida em relação ao depoimento de policiais carece de fomento jurídico, diante dos termos peremptórios do artigo 202 do Código de Processo Penal, cujos depoimentos, desde que verossímeis coerentes e não desmentidos pelo restante da prova, podem servir de base à decisão condenatória (RT 445/382). Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Habeas Corpus. Processual penal. Tráfico de entorpecentes. Condenação devidamente amparada no conjunto probatório dos autos. Testemunho policial. Eficácia probatória. Valoração das provas. Impossibilidade na via eleita. Precedentes do STJ. 1. Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório e aliado a outros elementos de prova a corroborar a condenação. 2. É inviável no presente writ a análise do valor das provas contidas nos autos para a condenação, uma vez que, além de ferir o princípio do livre convencimento do juiz, tal matéria escapa ao âmbito de apreciação do habeas corpus, em face da necessidade do exame minucioso do material cognitivo colhido no processo. 3. Ordem denegada” (HC 30776/RJ; Ministra Laurita Vaz, j. 03/02/2004, DJ 08.03.2004, p. 304).

De maneira semelhante, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

ROUBO - materialidade - auto de exibição, auto de reconhecimento de pessoa e prova oral que comprovam a subtração de bens das vítimas mediante grave ameaça. ROUBO - autoria - confissão dos acusados - validade - depoimento policial corroborando a versão da vítima - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual abuso por parte da autoridade - declaração de vítima imputando aos acusados a conduta delituosa - validade. CONSUMAÇÃO - ocorre com desapossamento - cessada violência ou grave ameaça. PENAS - base no mínimo - manutenção, ausente recurso ministerial - segunda fase - menoridade e confissão - não diminuição - penas que não podem ficar aquém do mínimo legal - terceira fase - concurso de agentes - aumento de 1/3 - reprimendas mantidas. REGIME - fechado - manutenção - gravidade do delito e circunstâncias judiciais desfavoráveis - único regime capaz de adimplir as funções da pena - provimento parcial aos recursos defensivos. (TJSP; Apelação Criminal 1500261-53.2018.8.26.0617; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jacareí - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/02/2022; Data de Registro: 25/02/2022)

Dano qualificado. Réu que danifica encanamentos da cela da cadeia pública de Capão Bonito, em que estava custodiado. Negativa do acusado isolada nos autos. Palavras dos policiais civis coerentes e seguras. Condenação bem decretada. Penas fixadas no

mínimo. Réu primário. Regime aberto adequado. Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Apelo improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1500084-82.2019.8.26.0123; Relator (a): Pinheiro Franco; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Capão Bonito - 2ª Vara; Data do Julgamento: 04/03/2022; Data de Registro: 04/03/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de entorpecentes e Associação para o tráfico. Recurso Defensivo e Ministerial. I - Preliminar de cerceamento de Defesa afastada. Resposta a acusação antes do recebimento da denúncia. Rito correto. II - Mérito. Condenação mantida. Provas suficientes da autoria e materialidade delitiva. Confissão de dois réus. Valorização das palavras dos policiais e prova da apreensão das drogas. Destinação mercantil dos entorpecentes deduzida, com segurança, pelas particularidades do caso concreto. Vínculo estável e duradouro comprovado. II - Penas alteradas. Aumento da base justificado. Majoração pela multirreincidência aplicada. Reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas. Pena de multa devida. Regime prisional mantido no fechado. APELOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS E PROVIDO, EM PARTE, O RECURSO MINISTERIAL. (TJSP; Apelação Criminal 0001756-43.2018.8.26.0542; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barueri - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/02/2022; Data de Registro: 18/02/2022)

Ficou claro que não há qualquer indício de parcialidade no depoimento dos policiais, uma vez que o acusado não indicou a existência de problemas pessoais com os agentes públicos e, portanto, não soube apresentar motivo apto a afastar a credibilidade dos depoimentos. Ainda, a versão dos policiais é amparada pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos periciais acostados nos autos, os quais comprovam a apreensão da droga mencionada.

A quantidade e a variedade de droga apreendida (22 porções de cocaína e 06 porções de maconha) afastam a alegação de porte para uso próprio. Ademais, os policiais já possuíam denúncias de que estava ocorrendo tráfico nas proximidades da Escola Estadual Pedro Brandão dos Reis e, quando passavam ao local, avistaram o réu, que adotou atitude suspeita, apta a justificar a abordagem.

Cite-se, aqui, lição de FERNANDO DE ALMEIDA PEDROSO, segundo o qual “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (cf. “Prova Penal”, ed., RT, 2004, item 5, pág. 96).

No mais, também foi encontrada a quantia de R\$ 59,00 (cinquenta e nove reais), em notas diversas cuja origem lícita não restou demonstrada. O réu alegou que o dinheiro se tratava de adiantamento das suas diárias de servente de pedreiro. Tal fato era de fácil comprovação, bastando ao réu arrolar, para oitiva em juízo, o patrão que teria realizado o pagamento ou, ainda, apresentar cópia de recibo do pagamento. Mas assim não o fez. Aliás, não teria sido crível que o réu tenha recebido adiantamento do valor no meio da semana e, ainda, antes do horário do término do expediente, já que os fatos ocorreram em uma quarta-feira, durante o período do almoço.

Sobre a posse de dinheiro de origem não esclarecida como elemento apto a confirmar a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – APREENSÃO DE DROGAS VARIADAS, INDIVIDUALIZADAS EM PORÇÕES E PRONTAS PARA VENDA NO VAREJO (DUAS PORÇÕES DE MACONHA PESANDO 287,5 GRAMAS E 7 PORÇÕES DE CRACK PESANDO 5,95 GRAMAS), ALÉM DE R\$ 340,00 EM DINHEIRO, FRUTO DA VENDA DE ALUCINÓGENOS, BEM COMO PETRECHO LIGADO AO NARCOTRÁFICO (BALANÇA DE PRECISÃO) – MERCANCIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO CORRETA – PENA BEM DOSADA – REGIME ADEQUADO – NÃO PROVIMENTO DO APELO. (TJSP; Apelação Criminal 0006944-85.2018.8.26.0196; Relator (a): Willian Campos;

Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 3ª Vara Criminal;
Data do Julgamento: 29/04/2020; Data de Registro: 29/04/2020)

TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRELIMINAR - Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Inocorrência - Rejeição. MÉRITO - Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Apreensão de considerável quantidade de entorpecentes (55 porções de cocaína, com peso de 29,8 gramas e 76 porções de maconha, com peso de 183,3 gramas), além de dinheiro e petrechos - Condenação mantida. PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO - Bases acima dos patamares. Quantidade de entorpecentes apreendidos. Exasperação na fração de 1/6. Proporcionalidade - Inviável o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. - Regime inicial fechado - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I e III) - Apelo provido em parte para reduzir as penas. (TJSP; Apelação Criminal 1502446-43.2019.8.26.0548; Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/04/2020; Data de Registro: 13/04/2020)

Deste modo, todos os elementos de prova, analisados conjuntamente, demonstram, de forma inequívoca, que a substância entorpecente pertencia ao acusado e se destinava à venda.

A Jurisprudência dos Tribunais é clara no sentido de elencar alguns, dentre os vários elementos de convicção a evidenciar a condição de traficante. Confira-se:

"Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a prisão" (Ap. Crim. 152.279.3, 3ª Câmara, j. 19.06.95 Rel. Des. Bittencourt Rodrigues).

"Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga à terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercância se destina o tóxico encontrado" (TJSP Ap. 187.915-3/2 Rel. CRISTIANO KUNTZ - RT 727/478).

"Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido (TJSP "RT"729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito" (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3, 3.8.94, p.8745).

Vale ressaltar que, para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes, basta a ocorrência de um dos verbos do tipo penal (artigo 33, Lei 11343/06), o que, neste caso, constitui o fato do réu trazer consigo o entorpecente apreendido pelos policiais, com o objetivo de vendê-lo, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O crime de tráfico ilícito de drogas é de natureza permanente, que se consuma com a simples posse pelo agente, para fim de entrega a terceiro, sendo, portanto, desnecessário que seja flagrado vendendo a droga.

Além do mais, pode coexistir, na mesma pessoa, a figura de traficante e usuário. O fato de, eventualmente, ser usuário de substância entorpecente não obsta ao reconhecimento da figura de traficante. Ao contrário, é natural que ambas as condições, a de usuário e a de traficante coexistam, pois, com a arrecadação obtida com a venda do entorpecente, possibilitar-se-á o emprego na compra, para que o vício possa ser sustentado.

Outrossim, conforme RT's 714/357 e 776/663, bem como Apelação Criminal apreciada pela Corte Estadual sob o nº. 993.08.018758-4, impõe-se ressaltar que a alegação de usuário ou de "viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a

última, de maior gravidade" (RJTJESP 101/498).

Verifico que o réu é reincidente e ostenta antecedentes (fls. 193/195), já que possui duas condenações com trânsito em julgado. Ainda, está presente a causa de aumento do artigo 40, III, Lei 11343, porque a infração foi cometida nas imediações de estabelecimento de ensino, conforme narrado pelas testemunhas. O réu foi abordado na lateral da escola, durante o horário de saída de alunos. Assim, a causa de aumento se justifica porque há maior reprovabilidade da conduta e risco intensificado para crianças e adolescentes, ainda que não tenha sido comprovada qualquer venda nas imediações da escola.

Deixo de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, pois o réu negou a finalidade de venda da droga apreendida.

Nesse contexto, comprovadas a autoria e materialidade, de rigor a condenação do acusado pela prática do delito descrito na denúncia. Passo à dosimetria a pena.

Na primeira fase, atendendo aos critérios do artigo 59 do Código Penal, verifico que o acusado é portador de maus antecedentes. As demais circunstâncias do artigo 59, CP são comuns aos delitos dessa natureza. Por essa razão, aumento a pena-base em 1/6, fixando-a em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e presente a agravante da reincidência.

Aumento a pena intermediária em 1/6, fixando-a em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena, sendo inviável o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11343/06, pois o réu é reincidente e portador de maus antecedentes. Presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11343/06. Aumento a pena em 1/6 e torno a pena definitiva em 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão e 793 dias-multa.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal (1/30 do salário-mínimo), devidamente atualizado, nos termos do artigo 49, § 1º 2º, CP e artigo 43, Lei 11343/06.

O regime inicial para o cumprimento da pena de prisão é o fechado. O crime reveste-se de gravidade em concreto, porque o acusado foi encontrado com variedade de substâncias entorpecentes, na proximidade de uma escola e em horário de saída de alunos. Além disso, o réu é reincidente e portador de maus antecedentes. O tempo de prisão provisória já foi considerado para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Destaca-se que, apesar da declaração de inconstitucionalidade da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" constante do §4º do art. 33, e da expressão "vedada a conversão de suas penas em restritivas de direito", constante do art. 44, da Lei 11.343/2006 (STF, HC 97.256/RS), o caso dos autos não permite a substituição da pena de prisão por penas alternativas, pois, ausente está o requisito objetivo do art. 44, I, do Código Penal, que estabelece pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, além de ausentes os requisitos subjetivos. Fica prejudicada a análise do artigo 77, CP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o réu ANDERSON LIMA DA SILVA, portador do R.G. n.º 44.386.880/SP, filho de André Luiz da Silva e Rosilei Cândida de Lima Silva, nascido em 03/11/1994 em José Bonifácio/SP, à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, e pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/2006. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, que serão exigíveis na forma do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual 11.608/2003.

O réu não poderá recorrer em liberdade, porque permanecem presentes os elementos e requisitos que autorizaram a decretação da prisão preventiva. Além da gravidade em concreto do delito, praticado nas imediações de escola, o réu é reincidente e portador de maus antecedentes. Portanto, a prisão continua necessária para a manutenção da ordem pública, evitando a reiteração criminosa.

Caso ainda não se tenha procedido na forma do artigo 50-A da Lei 11.343/06,

determino a destruição das drogas apreendidas, inclusive das amostras guardadas (artigo 72, Lei 11.343/06). Determino o perdimento do dinheiro apreendido, porque não comprovada a origem lícita.

Por fim, após o trânsito em julgado desta sentença: 1. Comunique-se à Justiça Eleitoral para suspensão dos direitos políticos do réu (art. 15, inciso III, da Constituição Federal). 2. Extraia-se a guia de execução definitiva, conforme artigo 105 da Lei de Execução Penal, observando-se o regime inicial fixado na condenação. 3. Oficie-se o Instituto de Identificação Civil.

Intime-se, pessoalmente, o réu, nos termos do artigo 392, inciso I, CPP.

Em seguida, pelo(a) Dr(a). Promotor(a) foi dito que não haveria interposição de recurso por parte do Ministério Público.

Em seguida, pelo(a) Dr(a). Defensor(a) foi dito que apresentará recurso, porém solicitou a intimação pessoal do réu, já que por problemas técnicos não ouviu a publicação da sentença.

7. PUBLICADO EM AUDIÊNCIA. SAEM OS PRESENTES INTIMADOS. SERVIRÁ A PRESENTE POR CÓPIA DIGITADA COMO MANDADO/OFÍCIO. Nada mais. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. José Bonifácio, 11 de agosto de 2022. Eu, Augusto César Cristal Lopes, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi. Meritíssima. Juíza - Documento assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006, conforme impressão à margem direita.